

1500367-70.2021.8.26.0306

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Resistência

Magistrado: Natália Berti

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Monsenhor Angelo Angioni, 1000, ., Jardim das Palmeiras - CEP 15200-000,

Fone: (17) 3245-4806, José Bonifacio-SP - E-mail: josebonifjec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500367-70.2021.8.26.0306

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Resistência

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2133300/2021 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 12574931 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO,

529/21/321 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 2133300 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ALEXANDRE DE ARAUJO BATISTA

Vítima:

A COLETIVIDADE e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

30/06/2022

Aos 30 de junho de 2022, às 09:30 horas, na sala virtual de audiências e utilizando-se da ferramenta Microsoft Teams, onde presente se encontrava a Exma. Senhora Doutora NATÁLIA BERTI, MMª. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de José Bonifácio/SP, comigo, Escrevente a seu cargo, ao final nomeada. Aberta a audiência com as formalidades de praxe, feito o pregão, verificou-se a presença digna representante do Ministério Público, na pessoa do Exmo. Sr. DR. CESAR BOCUHY BONILHA, Promotor de Justiça. Presente o(a) acusado(a) ALEXANDRE DE ARAUJO BATISTA. Presente seu(sua) defensor(a) constituído, DR. RENAN GONÇALVES ANTUNES - OAB/SP 332.729. Abertos os trabalhos, pela MMª. Juíza de Direito foi oportunizado ao réu exercer seu direito de entrevista prévia com seu(sua) Defensor(a) de forma virtual e reservada, nos termos do artigo 185, § 5º, do CPP. Em seguida, foi dada a palavra ao(à-s) Dr(a-s). Defensor(a-s) para o oferecimento de defesa preliminar, sendo pelo mesmo dito que: MMª. Juiz(a), o(a-s) acusado(a-

s) é(são) inocente(s) quanto à imputação que lhe foi(ram) feita(s) na denúncia, motivo pelo qual sua absolvição será reconhecida no decorrer do processo. Em seguida, pelo(a) MM^(a). Juiz(a) foi dito que: Diante dos depoimentos prestados na fase policial, verifico que há indício de autoria e prova da materialidade, razão pela qual RECEBO A DENÚNCIA. Em seguida, foi(ram) ouvida(s) a(s) testemunha(s) de acusação ALEXANDRO BATISTA DE AMORIM. Em seguida foi o acusado interrogado. ADVERTÊNCIA: Considerando a necessidade de dar celeridade aos processos em trâmite, esta audiência foi realizada por videoconferência. O Juízo e as partes fizeram uso da ferramenta Microsoft Teams recomendada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo para este fim. A audiência foi gravada em sistema audiovisual e será armazenada no programa SAJ, junto a este termo, sendo desnecessária a transcrição. Em seguida, pelo(a) MM^(a). Juiz(a) de Direito foi dito que: Digam as partes acerca de eventual diligência cuja necessidade se origine das circunstâncias ou fatos apurados na presente instrução. Em seguida, pelo(a) I. Dr(a). Promotor(a) foi dito que: MM^(a). Juiz(a) de Direito, nada a requerer. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Defensor(a) foi dito que: MM^(a). Juiz(a) de Direito, nada a requerer. Em seguida, pelo(a) MM^(a). Juiz(a) de Direito foi dito que: Declaro encerrada a instrução. Em seguida, o(a) Dr(a). Promotor(a) manifestou-se em alegações finais, gravado pelo sistema audiovisual. Em seguida, o(a) Dr(a). Defensor(a) manifestou-se em alegações finais, gravado pelo sistema audiovisual. Em seguida, pela MM^a. Juíza de Direito foi proferida a seguinte sentença, publicada em audiência:

Vistos.

ALEXANDRE ARAÚJO BATISTA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e no artigo 329, caput, do Código Penal, porque, no dia 04 de abril de 2021, por volta das 20h30m, na Rua Joaquim Moreira da Silva, 3.400, Jardim São José, nesta cidade e Comarca de José Bonifácio, ALEXANDRE ARAÚJO BATISTA, qualificado a fls. 43, trazia consigo, para uso próprio, uma porção da droga conhecida por maconha, em autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, pesando 3,92 gramas, apreendida a fls. 08 e periciada a fls. 16/18. Consta também que, no mesmo dia, hora e local, ALEXANDRE ARAÚJO BATISTA, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça contra o policial militar Alexandre Batista de Amorim, funcionário público competente para executá-lo. O denunciado transitava com seu veículo, quando acabou subindo na calçada. A polícia abordou-o e, em busca pessoa, encontrou a droga no bolso de sua calça. Ele foi convidado a fazer o teste do etilômetro, mas recusou-se. Os policiais solicitaram seu aparelho de telefone celular para vistoria, quando então ele recusou-se, tomando-se agressivo, passando resistir à abordagem policial. Foi necessário o uso de algemas para contê-lo, tendo sido encaminhado à delegacia de polícia. Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que o defensor foi ouvido sobre a denúncia, a testemunha foi inquirida, e o réu foi interrogado. O Ministério Público pediu a condenação, nos termos da denúncia. A defesa pediu a absolvição. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não havendo nulidades ou vícios a serem sanados. O réu foi representado por Defensor e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas. Assim, passo à análise do mérito. A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE, sendo as provas dos autos suficientes tão somente para condenação pelo artigo 28, da Lei 11.343/06. A materialidade delitiva deste delito está comprovada pelo inquérito policial (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fl. 08),

termo de declarações (fls. 13; 43), imagens (fls. 14/15), laudo pericial (fls. 16/21), documentos (fls. 31/37), termo de depoimento (fl. 39), relatório final (fls. 44/46), bem como pela prova oral produzida.

A autoria é certa.

Alexandro Batista de Amorim (testemunha de acusação) disse que o réu estava pelo Bairro Terra Nostra. Ele estava dirigindo em zigue zague e passou pelo canteiro central. Deram sinal de parada e ele não parou. Depois de um km, ele parou. Fizeram a abordagem. Encontraram uma porção no bolso dele, que parecia ser maconha. Ele estava com uma lata de cerveja aberta. No outro bolso, ele tinha 109 reais. Ele estava bem alterado e nervoso. Ele não queria ser abordado. Quando foram fazer a revista nele, ele segurava o celular e não queria deixar verificar o celular. Foi apreendida a droga e foi dada voz de prisão por porte de entorpecente e por dirigir embriagado. Em relação à droga, ele disse que era para consumo. Ele não era conhecido de outras abordagens. Foi a primeira vez que esteve frente a frente com ele. Ele se debatia para não encostar nele e fazer a revista nele. No calor da abordagem, ele não queria ser revistado. Ele chegou a encostar fisicamente para não ser abordado. Isso correu no momento que se debatia. Ele não queria entregar o celular. O problema era a entrega do celular. Pediram para entregar o celular e ele se recusou.

Alexandre Araújo Batista (réu) disse que tem 27 anos. É pescador profissional. A renda média é de R\$ 1500,00. É amasiado. Tem 3 filhos menores de idade, 2, 4 e 6 anos. Já respondeu a processo criminal. Disse que era Páscoa. O avô faleceu no dia. Precisou ir para Bonifácio para resolver algumas coisas do funeral. Foi à casa da cunhada. Deixou a esposa e saiu. Não subiu na calçada. O policial deu a ordem de parada, o depoente fez a rotatória e encostou. Ele mandou o depoente descer e ir para a viatura. O policial disse que ia revistar o carro e o depoente falou que iria acompanhar. Disse ao policial que tinha um cigarro de maconha, uma seda e um pedaço de maconha no bolso. Entregou a maconha para ele. Ele tentou pegar o celular e o depoente não deixou. Ele tentou pegar no seu pescoço. Não correu da abordagem, nem o ameaçou. Disse a ele que ele deveria tratá-lo corretamente. Nenhum outro policial fez nada. Ele deu ordem de prisão. A lata de cerveja estava fechada. No dia, tinha bebido na parte de manhã. Fez o exame de sangue. No dia, ligou para o cunhado na hora da abordagem. Ele não pediu a documentação do veículo. Não resistiu. Só segurou o celular. Ele segurou de um lado e o depoente segurou do outro. Não encostou nele, nem o agrediu em momento algum. Não se debateu. Na hora que ele questionou se tinha algo de errado, o próprio depoente falou que tinha o cigarro de maconha.

Finda a instrução processual, as provas produzidas nos autos são suficientes para fundamentar um decreto condenatório quanto ao delito de porte pessoal de substância entorpecente para o uso.

Na fase extrajudicial, o réu disse que: “estava saindo do bairro Terra Nostra, depois de ter deixado o seu cunhado de nome Marcos na residência dele, localizada naquele bairro, quando foi abordado por uma viatura da polícia militar; que, desceu do carro e a ele foi solicitado os documentos pessoais; que, chegou a perguntar para os policiais se eles iam vistoriar o veículo, sendo a ele respondido que sim; que, disse que ia ficar ao lado dos policiais para ver a revista em seu veículo, sendo impedido pelos policiais; que, os policiais militares tomaram o seu aparelho celular de suas mãos; que, disse aos policiais que estava apenas fumando um “baseado”, nada mais; que, iniciou-se uma discussão, quando os policiais o pegaram pelo pescoço, conduzindo-o ao Plantão Policial de José Bonifácio. No seu bolso havia a quantia de aproximadamente 350 (trezentos e cinquenta reais) em dinheiro, que acabou caindo pelo chão no momento da abordagem, sabendo que nesta delegacia de polícia foi apresentada a quantia de R\$109,00 (cento e nove reais) em dinheiro; que, disse para o policial Ronaldo, que ele não servia para ser policial, pois não era bandido e estava sendo muito mal tratado” (fl. 13).

O réu confirmou que estava fumando um “baseado”, embora tenha negado qualquer resistência à abordagem policial. Sobre o valor da confissão extrajudicial, ainda que parcial, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. Ação ajuizada para reconhecimento de nulidade por ausência de intimação do defensor, rescisão da condenação no mérito e mitigação das penas impostas. 1) Nulidade. Inocorrência. Prova documental da intimação prévia. Verificação em certidão dos autos. Nulidade afastada. 2) Manifesta contrariedade das provas. Inocorrência. Condenação apoiada nas provas orais. Retratação da petição tisdada pela mendacidade. Valor da confissão extrajudicial. Impossibilidade de conversão da revisão como terceira instância. Condenação originária mantida. 3) Penas. Dosimetria. Mitigação. Descabimento. Princípio da livre persuasão racional. Discricionariedade motivada. Fundamentação adequada. Elevação da pena-base acima do mínimo. Conformidade com os critérios legais. Improcedente. (TJSP; Revisão Criminal 0053976-97.2015.8.26.0000; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 4º Grupo de Direito Criminal; Foro de Piedade - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro: 13/11/2017).

No mesmo sentido, ouvido em juízo, novamente, o réu confessou que possuía a substância entorpecente com a finalidade de uso. Sobre o valor probatório da confissão livre e espontânea manifestada em pretório, releva colacionar a lição sempre atual de Júlio Fabbrini Mirabete, segundo o qual:

"... a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (MIRABETE, Júlio Fabbrini. - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo: Atlas, 2003, p. 288).

Não caminha em sentido diverso a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

"A confissão judicial, exceto especialíssimas circunstâncias, tem especial valor para o deslinde da causa, mormente quando se encontra em consonância com os demais elementos de convicção coligidos no processo, sob o crivo do contraditório não pairando dúvidas quanto à prática delituosa e à autoria atribuída aos apelantes. Assim, é o que basta para a fundamentação da sentença condenatória, ainda que fosse a confissão o único elemento incriminador apesar em desfavor dos réus, somente perdendo sua força se contrariada pelas provas colhidas em juízo, o que não é o caso." (Apelação Criminal 990.09.274150-0 - 14ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Dês. Marco Antônio de Lorenzi - Data de registro 23/04/2010).

Tal situação foi confirmada pela palavra do policial militar Alexandro, o qual declarou que o réu trazia a droga no seu bolso. Acrescentou que o réu não era conhecido dos meios policiais e que, durante a abordagem, confessou ser usuário de entorpecentes.

Nesse ponto, ressalto que é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório (RT 530/372). A crítica costumeiramente expendida em relação ao depoimento de policiais carece de fomento jurídico, diante dos termos peremptórios do artigo 202 do Código de Processo Penal, cujos depoimentos, desde que verossímeis coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória (RT 445/382). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de

policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada" (HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304).

De maneira semelhante, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Com efeito, a palavra de policiais deve ser tida como verdadeira se não demonstrado no curso da persecução penal qualquer contradição relevante ou de elementos que indiquem relações inamistosas entre estes e o acusado em juízo, porque presunção "jûris tantum" de veracidade. Note-se que os participantes da operação não ofertaram nenhum ponto obscuro ou nebuloso que se faça presumir estejam criando estratagemas para incriminar indistintamente inocente. Por consequência, infere-se, com a necessária segurança, que nada recomenda a colocação da pecha da suspeição nesses depoimentos. Agiram de maneira escorreita e sob o manto da legalidade, merecendo integral credibilidade seus depoimentos". (Apelação criminal nº 993.07.048506-0 - São Paulo - 4º Câmara de Direito Criminal - Relator Paulo Rossi - registrada em 21/07/2010).

PORTE ILEGAL DE ARMA - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito em relação a ambos os réus - Validade da palavra dos policiais - Condenação mantida - Pena e regime bem impostos - Descabimento de concessão de qualquer benesse a Alexsandro - Recursos desprovidos (voto nº 29642). (Apelação 0000968-48.2015.8.26.0408. Relator (a): Newton Neves. Comarca: Ourinhos. Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 19/07/2016. Data de registro: 20/07/2016).

Quanto ao delito do artigo 28, da Lei 11.343/06, pela natureza da droga (maconha), a confissão do réu e a quantidade encontrada, é verossímil que a droga se destinasse ao uso. Não há outros elementos, produzidos em fase judicial, para confirmar que a droga seria vendida.

Além disso, cumpre ressaltar que a tipificação, pelo ordenamento, do porte de entorpecente para uso próprio se mostra acertada, não se cogitando de qualquer inconstitucionalidade. Não há que se falar em mácula ao princípio da alteridade, uma vez que o bem jurídico tutelado é a saúde pública, e não a integridade física ou psíquica do usuário.

Igualmente, inexistente violação ao princípio da ofensividade em virtude da quantidade do entorpecente encontrado, visto que esse fator é elemento do tipo pelo qual foi o réu denunciado. Vale ressaltar, na esteira de posicionamento do Colendo Supremo Tribunal Federal, que a conduta do acusado, em virtude de sua perniciosidade e periculosidade social, não pode ser considerada penalmente irrelevante, não se aplicando, ao caso, o princípio da insignificância. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ÍNFINA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. EXISTÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO. PRECEDENTES. WRIT PREJUDICADO. I - Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. II - A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de

forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III - No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V - A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetivos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI - Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII - Habeas corpus prejudicado" (STF. HC 102940 / ES. Primeira Turma. Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 15/02/2011).

Diga-se, por fim, que a não cominação de pena privativa de liberdade à conduta em questão não compromete sua natureza de infração penal, conforme já assentado pelos Tribunais Superiores. Nesse sentido:

Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto despreço do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C. Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolição criminis (C. Penal, art. 107). II. Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado." (RE 430105 QO / RJ - RIO DE JANEIRO - QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento: 13/02/2007 - Órgão Julgador: Primeira Turma).

Por sua vez, quando ao artigo 329, do CP, entendo que as provas não são suficientes para fundamentar um decreto condenatório. Sobre o crime de resistência, ensina Celso Delmanto que "o núcleo é opor-se, que tem o sentido de resistir. O agente resiste à execução do ato legal, isto é, ato que está sendo executado no momento. Para a configuração do delito é necessário que a oposição seja mediante violência ou ameaça a funcionário (ou a quem lhe esteja prestando auxílio" (DELMANTO, Celso. DELMANTO, Roberto. DELMANTO JÚNIOR, Roberto. DELMANTO, Fábio M. De Almeida. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 816).

Na situação em análise, observo que o policial não narrou, de forma clara, um ato de ameaça ou violência (agressão) direcionado aos agentes públicos. Portanto, não

estão plenamente comprovados as elementares do tipo penal. Além disso, em que pese a manifestação do Ministério Público pela desclassificação para o delito de desobediência (artigo 330, do Código Penal), tal delito também não restou plenamente demonstrado.

Isto porque, o tipo penal indica a prática do delito quando o réu desobedece à ordem legal de funcionário público. In casu, o policial não deixou claro qual foi a ordem desobedecida pelo réu, dizendo apenas que ele se recusou a entregar o seu celular. E, sobre tal fato, convém destacar que o acesso a dados telefônicos, quando não há expressa autorização do titular, depende de autorização judicial. Ademais, no caso, não existiam elementos ou indícios da prática de outros delitos que justificassem a apreensão do objeto.

Assim, para o delito do artigo 329, do Código Penal, a absolvição por insuficiência de provas é medida de rigor.

Por fim, quanto ao delito do artigo 28, da Lei de drogas. Destaco que o réu é confesso, atraindo a incidência da atenuante da confissão espontânea. É reincidente, pois possui uma condenação transitada em julgado anterior aos fatos (fl. 94). O acusado também possui maus antecedentes, uma vez que, possui outra condenação criminal anterior à data dos fatos, ainda que com trânsito em julgado posterior (fl. 92).

Deveras, para fins de maus antecedentes, admite-se a condenação "por fato anterior, transitada em julgado após o novo fato" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado, 8ª ed. Saraiva, 2010, p. 274,), entendimento em consonância com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação - Homicídio tentado, qualificado por meio cruel - Recurso defensivo - Dosimetria - Pedido de redução da pena-base - Descabimento - Acréscimos bem justificados - Condenação por fatos anteriores apta a configurar maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado seja posterior - Precedentes do C. STJ e desta Câmara - Culpabilidade e consequências do delito aptas a embasar o acréscimo à reprimenda, nos termos do art. 59 do CP - Pretendido o reconhecimento da confissão espontânea - Impossibilidade - Acusado que não admitiu em momento algum do Plenário a prática delitativa - Redução mínima pela tentativa mantida, frente ao "iter criminis" percorrido pelo apelante - Regime fechado escoreito - Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0030011-34.2014.8.26.0224; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - Vara do Júri; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Roubos simples - Autoria e materialidade demonstradas - réu confesso - Dois roubos. Redução das básicas após afastamento dos maus antecedentes, uma vez que estes só se configuram quando há um fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime analisado. Mantida a compensação integral da reincidência, ainda que específica, com a confissão. Regime fechado mantido - o quantum da pena, que excede o quadriênio, somada à reincidência, demandam o equipamento fechado - tempo de prisão provisória é insuficiente para a alteração mais benéfica. Recurso da Defesa a que se dá parcial provimento. Negado atendimento ao recurso apresentado pelo Parquet. (TJSP; Apelação Criminal 1502327-21.2019.8.26.0536; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020)

Passo à dosimetria da pena.

Artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006

Na primeira fase, o acusado é portador de maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas, pelo que fixo a pena base em advertência.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Compenso-as e mantenho a pena mais branda já fixada, qual seja, a advertência.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena. Mantenho a

pena no patamar fixado.

Assim, apesar dos maus antecedentes e reincidência do réu, considerando que confessou a prática do delito e contribuiu para a elucidação dos fatos, aplico-lhe a sanção definitiva de advertência.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para: A) condenar o réu ALEXANDRE ARAÚJO BATISTA, portador do R.G. n.º 40.752.346/SP, filho de Odair Batista e Andreia Aparecida Leme de Araújo, nascido em 20/09/1994 em José Bonifácio - SP, aplicando-lhe a medida de ADVERTÊNCIA, por infração ao artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, b) absolver o réu ALEXANDRE ARAÚJO BATISTA, já qualificado, das sanções do artigo 329, caput, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, na forma da lei, observando-se o teor do artigo 98, §3º, CPC.

O réu poderá recorrer em liberdade por esse processo, pois estão ausentes os requisitos da custódia cautelar.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, diante da prolação da sentença.

Após o trânsito em julgado: oficie-se ao Instituto de Identificação Civil; comunique-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, III, CR; realizem-se as anotações e comunicações de praxe, arquivando-se os autos, oportunamente.

Após a prolação da sentença, foram questionadas as partes acerca do interesse em recorrer. Em seguida, dada a palavra ao Ministério Público foi dito que: "M.M Juíza, concordo com a sentença aplicada e renuncio ao direito de recorrer". Dada a palavra ao Advogado e ao réu foi dito que: "M.M Juíza, concordo com a sentença aplicada e renuncio ao direito de recorrer". Em seguida, foi aplicada a medida de advertência ao sentenciado, momento em que foi alertado sobre os efeitos destrutivos do uso de entorpecentes. Pela M.M. Juíza determinou-se que a z. Serventia certifique o trânsito em julgado, a aplicação da medida imposta, bem como que se expeça certidão de honorários ao Advogado nomeado. Publicada em audiência, saem as partes intimadas. Regularizados, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. NADA MAIS, saindo os presentes intimados. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Larissa Luana do Amaral, matrícula 368.649, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.